

1018128-92.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Ricardo Felicio Scaff

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... que a suspensão se deu por de furto do aparelho celular, procedimento jamais requerido ou informado pela autora tampouco verossímil; ao final, solicitou administrativamente a reativação de sua linha telefônica, o que, contudo, não ocorreu sob a justificativa de que a autora havia realizado portabilidade de sua linha telefônica, fato este que alega jamais ter acontecido, com que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Cível

Rua dos Crisântemos, nº 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1018128-92.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1018128-92.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Fernanda Caliente de Souza Borges

Requerido:

CLARO S/A

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Ricardo Felicio Scaff

Vistos.

FERNANDA CALIENTE DE SOUZA BORGES, qualificada nos autos, ajuizou presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais contra CLARO S/A, também qualificada nos autos, alegando, em suma, que possui plano telefônico móvel pré-pago e que, em 14.04.2022, ocorreu suspensão de sua linha, em que se viu sem acesso à internet móvel e rede telefônica para ligação. Narrou que após diversos chamados de atendimentos junto à operadora, inicialmente foi informada que a suspensão se deu por de furto do aparelho celular, procedimento jamais requerido ou informado pela autora tampouco verossímil; ao final, solicitou administrativamente a reativação de sua linha telefônica, o que, contudo, não ocorreu sob a justificativa de que a autora havia realizado portabilidade de sua linha telefônica, fato este que alega jamais ter acontecido, com que não se conforma. Requereu, portanto, obrigação para ré reativar sua linha e plano telefônicos, sob pena de multa, bem como condenação ao pagamento de R\$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Pleiteou a concessão da gratuidade judiciária. Postulou a procedência dos pedidos (fls. 01/23).

Com a inicial vieram documentos (fls. 24/66).

A autora emendou a inicial (fls. 69).

A r. decisão concedeu para a autora os benefícios da justiça gratuita (fls. 78/79). Devidamente citada, a ré apresentou contestação defendendo, em sede de preliminares, ilegitimidade passiva. No mérito, suscitou que não houve falha na prestação de serviço e a regularidade do procedimento de portabilidade, solicitado em 02.04.2022 e sendo concluído em 16.04.2022. Impugnou o alegado dano e seu respectivo valor. Postulou a improcedência dos pedidos (fls. 84/98). Juntou documentos (fls. 99/146).

A autora ofertou réplica (fls. 213/218).

Instadas as partes para especificarem provas a produzir, as partes dispensaram a dilação probatória (fls. 222 e 223).

Os autos vieram conclusos para pronto julgamento.

É o relatório.
Decido.

O presente feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, desnecessária a dilação probatória além dos documentos já encartados aos autos, remanescendo apenas questões de direito. Cumpre observar que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

Consigno que, à vista da natureza do negócio celebrado, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável na hipótese, visto que a parte autora é destinatária fática e econômica dos serviços fornecidos pela ré (artigos 2º, 3º e 17 da Lei de nº 8.078/90).

O sistema de proteção do consumidor, previsto no artigo 3º da mencionada lei, considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor.

Nesse cenário, a empresa acionada enquadra-se no conceito de fornecedora, na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e integrando uma cadeia de consumo, tem ela responsabilidade pelos serviços e produtos disponibilizados aos seus consumidores, nos termos do artigo 7º parágrafo único, do mesmo diploma legal, razão pela qual afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré.

À míngua de outras preliminares e questões processuais pendentes, passo a analisar o mérito.

Os pedidos formulados na inicial são procedentes, pelas razões em seguida elucidadas.

Narra a autora que houve a portabilidade de seu número de telefone móvel da operadora Claro para a operadora Vivo, sem sua solicitação, o que lhe causou transtornos, pois, além de ter tentado solucionar o problema através de diversas ligações telefônicas e atendimento presencial nas lojas da ré, sem sucesso, até o momento não houve restabelecimento dos serviços. Por esse motivo, requer a reativação da sua linha telefônica e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Frise-se, por oportuno, que a ré, na condição de fornecedora, está jungida à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, sendo assim,

aplicável o código protetivo, incidindo ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, regra contida no artigo 6º, inciso VIII do diploma consumerista.

Nessa toada, a responsabilidade do réu é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, à vista da teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade lucrativa que implica necessariamente a assunção dos riscos a ela inerentes, competindo ao demandado a prova da idoneidade de suas operações.

No caso dos autos, a ocorrência da portabilidade restou incontroversa.

Os documentos juntados com a petição inicial demonstram o recebimento de e-mail informando o cancelamento da linha da autora junto à empresa ré e, somente após diversas tentativas de restabelecimento da linha, foi informada que foi realizada a portabilidade e que o número da autora passou a ser da operadora Vivo, sem seu conhecimento.

Com isso, a autora dirigiu-se até loja da empresa Vivo para verificar se, de fato, houve tal portabilidade, obtendo resposta negativa. Assim, descreveu diversas ligações que realizou, para a ré, na tentativa de solucionar o problema, informando os respectivos números de protocolo (fls. 21).

Não prospera a alegação da requerida Claro no sentido de que os danos causados decorreram unicamente da conduta da operadora Vivo, pois, sendo a operadora receptora, foi quem realizou a portabilidade.

Isso porque, tanto a prestadora doadora, como a prestadora receptora, participam dos processos de portabilidade, nos termos do artigo 39 e 63, §1º, da Resolução 460/2007 e artigo 7º, § único, da Lei 8.078/90, cabendo a elas utilizarem métodos seguros para conferência e confirmação dos usuários.

Nesse passo, caberia à empresa ré o dever de checar a regularidade das operações efetivadas e recusar o pedido. Diante do extrato de tela do sistema apresentado pela requerida (fl. 90), é notória a irregularidade da portabilidade efetuada, tendo em vista que o nome da titular da linha sequer é o da autora. Sendo assim, patente a culpa da ré por negligência nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil.

Tendo em vista que a autora expressamente consignou não ter efetuado solicitação de portabilidade, era ônus da ré provar a sua regularidade, o que não ocorreu, não tendo demonstrado sequer uma justificativa plausível para deixar de apresentar os atendimentos de números de protocolo informados na inicial.

Tal interpretação decorre do previsto artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, observadas a hipossuficiência técnica do consumidor relativamente ao sistema de informações da operadora e a impossibilidade de produção de prova negativa, uma vez que a consumidora não tem como provar que a solicitação não foi feita por ela.

Destarte, a restituição da linha telefônica à autora, é a medida que se impõe e, sendo incontestável a ilegitimidade da portabilidade realizada, incumbe à ré reparar os prejuízos causados à consumidora.

O artigo 186 do Código Civil traz os pressupostos fundamentais para que haja o dever de indenizar, dispondo que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 187 do mesmo diploma legal consagra o abuso do direito como hipótese de ato ilícito. A seu turno, o artigo 927 da lei civil

estabelece que todo aquele que por ato ilícito causar dano fica obrigado a repará-lo.

Tratando-se de relação consumerista, o fornecedor é responsável independentemente da existência de culpa pelos danos causados ao consumidor, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para tal, exige-se a presença dos pressupostos da obrigação de reparar, quais sejam: a conduta do fornecedor, o dano causado ao consumidor e o nexo causal entre ambos, prescindindo-se, porém, de análise da culpa do agente.

Restam presentes, portanto, os requisitos configuradores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a conduta da operadora ré, os danos causados à parte autora e o nexo causal entre ambos.

Desse modo, no que tange aos danos morais, trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso, valendo dizer que o dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo psíquico sofrido.

A empresa ré era a operadora responsável pela linha e, mesmo após ter sido contatada pela consumidora, não resolveu o problema, apenas encaminhando-a de um setor para outro, desperdiçando seu tempo útil.

Sendo assim, à hipótese também se aplica a chamada teoria do desvio produtivo, pela qual um erro do fornecedor obriga ao consumidor perder dias ou semanas para resolver a situação, o que não se pode permitir.

O entendimento aqui exposto é corroborado pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ementa a seguir transcrita, in verbis:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Portabilidade não autorizada da linha telefônica da parte autora, com posterior atribuição do número a terceira pessoa. Demanda ajuizada em face das duas operadoras envolvidas na portabilidade. Sentença de procedência, com condenação solidária das corrés ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R\$ 8.000,00. Irresignação de ambas as rés. Preliminar de ilegitimidade passiva da Telefônica Brasil S/A afastada. Operadoras doadora e receptora envolvidas na portabilidade que possuem responsabilidade pelo procedimento, nos termos da Resolução nº460/2007 da Anatel. Parte autora que afirma não ter solicitado a migração de sua linha da Vivo para a Nextel, após a qual ela não mais teve acesso ao seu número. Relação consumerista caracterizada na hipótese em exame, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo demonstrado a regularidade da portabilidade. Elementos dos autos a demonstrar que o procedimento ocorreu à revelia da parte requerente, que acabou perdendo o número de seu telefone, tendo a sua conta do 'whatsapp' passado a constar, na sequência, como conta comercial denominada "~SUPORTE ONLINE SANTANDER". Falha na prestação dos serviços evidenciada. Conduta das corrés, consistente na portabilidade indevida da linha da autora, com posterior atribuição do número de telefone a terceira pessoa, que ultrapassa o mero aborrecimento. Parte autora que ficou impossibilitada de utilizar linha móvel de longa data, além de exposta à prática de fraudes mediante a utilização de seu número de telefone. Situação ocorrida em contexto pandêmico, 03 dias após a requerente, professora, ter sido orientada por sua empregadora a realizar atividades por meio de aplicativos de celular, dentre os quais o 'whatsapp', de que a parte parou de dispor em decorrência da alteração de seu número. Descaso das prestadoras do serviço para com o consumidor evidenciado pela não resolução da questão mesmo após reiteradas reclamações administrativas. Dano moral configurado. Montante indenizatório que atendeu às peculiaridades do caso em tela e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução. Juros

de mora incidentes a partir da citação. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recursos não providos" (TJSP; Apelação Cível 1001536-21.2020.8.26.0457; Relator Des: Walter Barone; 24ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022).

É fato que os julgados aqui apontados são precedentes persuasivos sem eficácia vinculante, porém, conforme leciona o jurista José Rogério Cruz e Tucci em sua obra "Precedente judicial como fonte do Direito". São Paulo: RT, 2004, pg. 13, tais julgados constituem indício de uma solução racional e socialmente adequada.

Sendo certo o dever de indenizar o dano, passo a fixar o valor do quantum.

No que tange à indenização pelos danos morais, o valor respectivo deve ser o suficiente para possibilitar uma satisfação à pessoa, como maneira de minimizar o sofrimento moral, e sancionar o lapso cometido, a fim de viabilizar uma maior cautela no trato com as pessoas.

A indenização não pode caracterizar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser ínfima, a ponto de nada refletir em termos de punição civil.

Nos presentes autos, a fim de que a indenização signifique medida profilática em relação à ré, sem que signifique ao mesmo tempo enriquecimento ilícito à parte autora, deve a compensação financeira ser fixada na ordem de R\$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada, considerando as peculiaridades do caso concreto, razoável e em valor condizente com os parâmetros adotados pelo E. Tribunal de Justiça Bandeirante.

No que tange aos consectários incidentes sobre a indenização a título de danos morais por ato ilícito no caso de responsabilidade contratual quanto à obrigação ilíquida (mora ex persona), os juros moratórios (de 1%) fluem a partir da citação e a correção monetária, desde o arbitramento, à luz do disposto na Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e nos artigos 397, § único, 405 e 406 do Código Civil, este cumulado com o artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Por fim, anoto que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (ex vi do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto e considerando que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor para: (i) determinar que a ré reative a linha telefônica da autora, no prazo de 10 (dez) dias a contar dessa decisão, sob pena de multa diária no valor de R\$ 250,00, limitada a R\$ 5.000,00 - na inércia da ré, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos, cujo valor será apurado em regular liquidação; (ii) condenar a ré a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R\$ 5.000,00, atualizada monetariamente desde o arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A atualização monetária será feita pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo por critérios de equidade e razoabilidade em R\$ 1.500,00, nos termos dos artigos 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-

se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, e, após, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (artigo 1.010, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil).

Para fins de recurso, deverá ser recolhido o preparo no importe de 4% sobre o valor da condenação, se houver, ou caso não haja, ou não seja possível desde logo apurar o montante, sobre o valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado, tendo em conta o Provimento CG n. 16/2016 e Comunicado n. 438/2016, a parte credora deverá dar início à execução da sentença (cumprimento da sentença), no prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo sem providências, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 09 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA